

1500372-61.2021.8.26.0575

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcelo Luiz Leano

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... em dinheiro. Além disso, havia denúncia no sentido de que o Réu praticava o tráfico de drogas. A existência desses elementos na residência do acusado indica que ele se dedicava ao comércio de drogas. Não se trata, tendo em vista a quantidade das drogas apreendidas, os petrechos usados para o tráfico e o dinheiro recolhido, de tráfico pontual ou isolado exercido pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

2ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500372-61.2021.8.26.0575 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500372-61.2021.8.26.0575

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2122353/2021 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 17735596 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 632/21/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2122353 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO AFONSO OLIVEIRA GOMES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Marcelo Luiz Leano

Vistos.

PEDRO AFONSO OLIVEIRA GOMES, qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 61 inciso II, "j", do Código Penal, porque, conforme consta da peça acusatória, no dia 05 de maio de 2021, por volta das 12h, na Rua João Quessada, neste Município e Comarca de São José do Rio Pardo, trazia consigo e guardava, com fins de tráfico, 66 pedras de crack, substância feita à base de cocaína, pesando, ao todo, 20,76g; e 76 pinos de cocaína, pesando, aproximadamente, 92g, sem autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar.

Auto de prisão em flagrante (fl. 01). Auto de exibição e apreensão às fls. 14/15; auto de constatação preliminar às fls. 16/17; e laudo químico-toxicológico às fls. 129/140.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva ao acusado e determinada a destruição das drogas apreendidas (fls. 53/56).

Regularmente notificado (fl. 87), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 105/106).

A denúncia foi recebida (fl. 107) e, o réu, citado (fl. 128).

Mantida a prisão preventiva do réu (fls. 97/98 e 151/153).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação; posteriormente, o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público pediu a condenação do réu, pois entendeu provados todos os elementos típicos descritos na denúncia, em especial a materialidade e a autoria do delito, bem como o tipo subjetivo próprio da espécie. Em contrapartida, a Defesa pugnou pela absolvição do acusado (cf. mídia digital arquivada no sistema SAJ).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido estatal punitivo é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição e apreensão às fls. 14/15; auto de constatação preliminar às fls. 16/17; e laudo químico-toxicológico às fls. 129/140.

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

Do mesmo modo, a autoria da prática delitiva restou incontestada. Vejamos.

Segundo restou apurado, Pedro Afonso praticava tráfico de drogas nesta cidade e, para tanto, guardava e trazia consigo a quantidade de droga acima descrita. Assim, nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, policiais militares em patrulhamento pelo local (conhecido como ponto de venda de entorpecentes) presenciaram o denunciado, acompanhado dos adolescentes Alex Vinicius Monteiro Sabino e Daniel Teodoro da Silva Godoi, promovendo o tráfico de drogas naquele local. Os policiais constataram que estes se "revezavam" na venda de drogas aos usuários que ali chegavam. Diante de tal quadro, os policiais deliberaram pela abordagem do denunciado e dos referidos adolescentes que o acompanhavam que, ao verem a aproximação da guarnição, tentaram fugir. Entretanto os policiais conseguiram visualizar o momento em que Pedro Afonso dispensou um pochetto ao solo durante a tentativa de fuga. Logo em seguida, o denunciado foi abordado. Em revista pessoal, foi encontrada em sua bermuda a quantia de R\$ 17,00 (dezessete reais) em dinheiro. Após, recolheram a poquette dispensada momentos antes por Pedro Afonso e constataram que este estava na posse de drogas visto que no interior daquela bolsa havia 66 pedras de crack e 76 pinos de cocaína. A finalidade mercantil dos entorpecentes fica patente ante a natureza, forma de acondicionamento (porções individualizadas), variedade e quantidade de drogas apreendidas, apreensão de valores, bem como as demais circunstâncias da localização das drogas.

Vale destacar que, em que pese as referidas declarações terem sido tomadas na fase inquisitiva, nada obsta sua utilização como reforço da tese acusatória. Não se diga com isso que a prova produzida na fase policial sirva exclusivamente para determinar a condenação de alguém, mas, somada aos diversos outros elementos produzidos em juízo, pode ser admitida como fator a mais a amparar a acusação.

Em juízo, o policial militar João Paulo Gonçalves Parra disse que Pedro Afonso, vulgo "Cabeção" trata-se de figura muito conhecida nos meios policiais, inclusive já foi visto em outras ocorrências traficando, oportunidades em que conseguiu se evadir. O local da ocorrência, também, há tempos conhecido por ser ponto de venda de drogas, chamado de "Biqueira do SBT". Na ocasião ora analisada, observaram Pedro Afonso e mais 02 pessoas se revezando no tráfico de entorpecentes. Após

presenciarem 04 vendas de drogas, decidiram pela abordagem. Um condutor do veículo saiu em disparada, ao passo que Pedro Afonso correu, dispensando a pochete que estava na cintura. Os adolescentes que acompanhavam o acusado empreenderam fuga, dos quais um também dispensou algo, sendo estes e o réu, continuamente, alcançados. Entrevistado, o acusado sustentou que correria porque se assustou com os agentes policiais. Com apoio de outra viatura policial, voltaram ao local onde Pedro Afonso havia dispensado a pochete e, em seu interior, localizaram 76 pinos de cocaína, 66 pedras de crack e R\$ 17,00. Já na sacola dispensada pelo menor, depois identificado como Alex, localizaram 42 pinos e 26 pedras das mesmas drogas, além de R\$ 15,00 com o adolescente Daniel (cf. mídia digital arquivada no sistema SAJ).

Em mesmos termos foram as declarações de seu colega de farda, o PM Rivaldo Luciano Tonhão. Relatou que Pedro estava praticando atividade de tráfico no ponto de drogas conhecido como “biqueira do SBT”. Rivaldo e seu companheiro esconderam-se e flagraram Pedro e mais 02 indivíduos efetuando de 04 a 05 vendas. O acusado estava com uma pochete e um dos menores com uma sacola. Visto isso, os policiais partiram para abordagem. Quando os infratores se deram conta dos policiais, tentaram empreender fuga, porém, conseguiram abordá-los. Em busca pessoal, foi encontrado R\$ 17,00 com Pedro e mais R\$ 15,00 com um dos menores identificado como Daniel, vulgo “China”. Ao voltarem ao local em que foram dispensados os entorpecentes no momento da fuga, localizaram na pochete de Pedro 76 pinos de cocaína, 66 pedras de crack, ao passo que na sacola em que o outro menor, Alex, dispensou, foram encontrados, ainda, 42 pinos de cocaína e 26 pedras de crack. Entrevistado, Pedro, no momento da abordagem, negou estar traficando, mas não soube explicar o que fazia naquele local, apresentando-se agressivo e se intitulado membro de uma facção criminosa de prefixo 016 (cf. mídia digital arquivada no sistema SAJ).

O acusado, em solo judicial, negou a prática do delito a ele imputado. Segundo ele, no dia dos fatos, tinha acabado de cortar o cabelo numa barbearia, que fica próxima ao ponto de drogas. Os policiais abordaram-no em frente à barbearia, e, mais adiante, outros dois menores. Perguntou o motivo de estar sendo preso, foi quando o disseram que seria por conta de seu celular, entretanto, no momento em que chegou à Delegacia de Polícia, os policiais surgiram com uma pochete cheia de drogas para incriminá-lo.

Essa é a prova oral colhida.

Entretanto, em que pese a negativa do acusado nessa fase processual, sua narrativa não merece acolhimento, porquanto ela restou isolada nos autos, sobretudo quando confrontadas com as demais provas colhidas durante a instrução processual – todas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Cabe salientar que os policiais, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram uníssonos, coerentes e convincentes. Deste modo, é necessário valorizar tais depoimentos pelo fato de que são agentes públicos que agem no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, calcados na boa-fé presumida, e, assim, são merecedores de toda a confiança, equiparados por qualquer indivíduo do corpo social há de merecer, até que o conjunto probatório confirme em contrário, inexistentes, outrossim, no caso em testilha.

Nesse sentido:

“DEPOIMENTO POLICIAL VALIDADE. Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser questionado mediante impugnação específica e não somente pela origem – Condenação mantida” (TJSP. Apelação nº 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator: Amado de Faria. Julgamento em 09/02/2012).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,

age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Eventuais e pequenas contradições quanto a fatos secundários nos relatos policiais são irrelevantes e normais. O que importa para a higidez da prova é a coesão das versões em seu conteúdo principal.

As circunstâncias da prisão em flagrante, a apreensão de quantidade e variedade de drogas, o montante em dinheiro encontrado e o local onde o acusado fora visto evidenciam o intuito da mercancia. Neste azo, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele trazia consigo e guardava, com fins de tráfico, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Incabível findar em decisão de mérito absolutório e a argumentação em que pese a ausência de indícios suficientes de autoria, flagrante ilegalidade e fragilidade dos elementos indiciários para sustentar a proposição acusatória, como pretende a Defesa.

Ainda, seguindo essa linha, a quantidade de drogas, alinhado a outros elementos de prova, acima mencionados, formam um conjunto probatório digno de imputar ao réu esta conduta criminoso.

Nesta ótica:

"Para caracterização do tráfico de entorpecentes, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida - Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização". (TJ-SP - APL 0005767-21.2017.8.26.0132 SP 0005767-21.2017.8.26.0132, julgado em 31/01/2019, rel. Desemb. Sérgio Ribas). "Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de 'trazer consigo'. Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes". (TJ-SP - APL 0001285-53.2017.8.26.0189 SP 0001285-53.2017.8.26.0189, julgado em 08/11/2018, rel. Desemb. Grassi Neto).

Ademais, foi encontrada quantia em espécie com o acusado. Corroborando esta conclusão, cito alguns julgados:

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus commissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. No caso, o decreto preventivo ancorou-se, fundamentadamente, no disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, no desiderato de acautelar a ordem pública, considerando a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, acondicionados em invólucros plásticos dentro de um tubo de PVC (110g de maconha e 83,28g de cocaína), além da elevada quantia em dinheiro em notas trocadas (R\$ 4.469,00) e a balança de precisão encontradas em poder do custodiado. 3. Admitida a segregação cautelar quando a diversidade e a quantidade de substâncias encontradas, aliadas à apreensão de dinheiro e apetrechos destinados ao fabrico de entorpecentes, evidenciam a necessidade de resguardar a ordem e a saúde públicas. Precedentes. 4. Recurso ordinário desprovido." (STJ - RHC: 51424 MG 2014/0229982-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/03/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2015) - **negrito aposto.**

"HABEAS CORPUS Crime de tráfico de drogas Pedido de revogação da prisão preventiva Falta de fundamentação IMPOSSIBILIDADE Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente fundamentada suficientemente Garantia da ordem pública evidenciada pelas circunstâncias que envolvem o fato, notadamente a quantidade de droga apreendida (10 pedras de "crack" e 20 invólucros de cocaína) e a quantia de R\$114,00, em dinheiro trocado, tudo localizado com o paciente Presente indícios de autoria e materialidade - Dúvida que milita em favor da sociedade Presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, sendo insuficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão - Ordem denegada." (TJ-SP - HC: 664163320128260000 SP 0066416-33.2012.8.26.0000, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro. Data de Julgamento: 31/07/2012, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/08/2012) - **negrito aposto.**

Relevante tal informação, pois é comum que as substâncias entorpecentes sejam vendidas em pequenas quantidades e porções individualizadas, por valores recolhidos em trocados pelos traficantes.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputada ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Além da materialidade e da autoria delitiva, também restou provada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, haja vista os policiais militares alhures mencionados terem descrito que o réu praticava o tráfico de drogas na companhia de dois adolescentes.

A respeito, todos foram vistos juntos, trabalhando em conluio na venda de ilícitos. Conforme publicação em 18/5/2020 do acórdão de mérito proferido no Recurso Especial nº 1.619.265-MG, processo-paradigma do Tema nº 1052 - Qualificação - Menor - BO - Documento - do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, o STJ afetou e julgou o mérito do recurso, em que fixada a seguinte tese jurídica: Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento. A comprovar, têm-se nos autos os documentos probantes, boletim de ocorrência de fl. 08/11 e certidão de nascimento encartado à fl. 20.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico e com fundamento no artigo 59 do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, passo a analisar a primeira fase. Aqui, conquanto a quantidade de entorpecentes mostra-se expressiva para esta urbe, referida circunstância será considerada para análise da aplicabilidade ou não do privilégio previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Desse modo, fixo a pena em seu mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes a serem valoradas, resta a pena acima fixada. Lado outro, conquanto os fatos tenham ocorrido em momento reconhecido como calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, não se observa o caso de se aplicar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. Entretanto, para a aplicação da agravante em testilha, o agente deve se valer de facilidades que decorrem do momento, seja em razão da fragilidade da vítima, seja em razão da menor capacidade do estado policial, o que não foram demonstrados aos autos. Dessa forma, estando a pena acima fixada no mínimo, resta mantida no patamar acima declinado.

No terceiro estágio incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, visto que a infração foi cometida na companhia de adolescentes. Assim, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em contrapartida, inexistem causas de diminuição de pena a serem valoradas, pois o réu não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. No caso, o réu não preenche os requisitos legais, já que a benesse penal em questão é dirigida a pessoas que se envolveram com a traficância de forma pontual, ocasional, e, embora o acusado seja primário, é de se considerar a expressiva quantidade de entorpecente encontrada, tratando-se de hipótese para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal ora analisado. A respeito, tem-se o precedente do STF:

Não é crível que o réu, surpreendido com mais de 500 kg de maconha, não esteja integrado, de alguma forma, a organização criminosa, circunstância que justifica o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (STF. 1ª Turma. HC 130981/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/10/2016). (...) In casu, a paciente, na condição de "mula", foi surpreendida transportando expressiva quantidade de droga ao exterior. Tal fato afasta o preenchimento dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (...) - STF. 1ª Turma. HC 123430, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14/10/2014.

Ainda, sobre o tema:

" (...) Outrossim, há que se considerar que na residência do Réu foram encontrados os seguintes produtos: (i) 179 fraconetes plásticos contendo cocaína, pesando cerca de 200g, (ii) uma porção de cocaína com peso aproximado de 39g, (iii) 19 tijolos de Cannabis sativa L, droga conhecida como maconha, pesando cerca de 2,059kg, (iv) 3 balanças de precisão, (v) 5 rolos de plástico filme, normalmente utilizado para embalar drogas, (vi) 2 aparelhos celulares e (vii) R\$ 650,00 em dinheiro. Além disso, havia denúncia no sentido de que o Réu praticava o tráfico de drogas. A existência desses elementos na residência do acusado indica que ele se dedicava ao comércio de drogas. Não se trata, tendo em vista a quantidade das drogas apreendidas, os petrechos usados para o tráfico e o dinheiro recolhido, de tráfico pontual ou isolado exercido pelo Réu, não sendo o caso, portanto, de aplicação do chamado tráfico privilegiado. Nesse mesmo sentido, Renato Brasileiro: (...) se o indivíduo for flagrado com grande quantidade e variedade de drogas, tem-se aí forte indicativo de que se trata de agente dedicado a atividades criminosas, até mesmo porque não é normal que um traficante pequeno e eventual dê início às atividades de traficância com tamanha quantidade e diversidade de drogas (Legislação criminal especial comentada: volume único / Renato Brasileiro de Lima - 4 ed. - Salvador: JusPODIVM, 2016)". No mesmo sentido são os seguintes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça: 6ª Turma HC 174.547/SP, Rel Min Og. Fernandes, j. 17.02.2011, DJE 07/12/2011 e 5ª Turma, HC 148.148/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.11.2009, DJE 15/12/2009.

No presente caso, é de se considerar, ainda, as passagens pela Vara da Infância e Juventude por ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas (cf. certidões de fls. 89/95), hipótese para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal ora analisado. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL. MODO INTERMEDIÁRIO ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA

ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 3. Hipótese em que o Tribunal de origem negou a aplicação da minorante por entender que a quantidade dos entorpecentes apreendidos (219,8 gramas de maconha e 1,6g de cocaína) e o registro de atos infracionais na adolescência, inclusive análogos ao tráfico de entorpecentes, comprovam a habitualidade delitiva do paciente. Logo, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Esta tem Corte decidido que o envolvimento do paciente quando menor em atos infracionais, sobretudo quando relacionados ao crime de tráfico de entorpecentes, podem justificar a não aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto demonstra a dedicação do agente a práticas criminosas. 5. Mantido o quantum da pena do paciente em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, inviável a fixação do regime aberto, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos exatos termos dos arts. 33, § 2º, 'b', e 44, I, ambos do Código Penal. 6. Habeas corpus não conhecido." (HC 537.485/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019; sem grifos no original).

Por fim, o acusado possui processo em andamento por associação ao tráfico de entorpecentes. Ainda que processos em andamento não gerem reincidência ou maus antecedentes, trata-se de hipótese para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal ora analisado. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS Nº 591477 - RS (2020/0151534-3) RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR IMPETRANTE : ANDREA GARCIA LOBATO ADVOGADA : ANDRÉA GARCIA LOBATO - RS069836 IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PACIENTE : ANDERSON MELCHIOR MARTINS HAMMES (PRESO) INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 77 KG DE MACONHA. DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE PELA QUANTIDADE DE DROGA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6. NÃO OBSTANTE PROCESSOS EM ANDAMENTO, O PACIENTE É PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. Ordem de habeas corpus concedida, nos termos do dispositivo. DECISÃO. (...) Na terceira etapa da dosimetria da sanção, presente a causa de aumento antevista no inciso V do art. 40 da Lei de Drogas, ela foi ampliada no menor patamar - 1/6, restando estipulada em seis anos e três meses de reclusão. Por fim, o castigo foi abrandado devido à causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, restando ele definitivamente estipulado em cinco anos, dois meses e quinze dias de reclusão. E aqui reside adequadamente um ponto do recurso ministerial, tendo em vista que não se cuida de condenado com bons antecedentes, embora tecnicamente primário (fls. 198/200). Destaco entender que os bons antecedentes exigidos na Lei de Drogas não são os mesmos para a ponderação negativa na basilar, até por que se assim fosse, não haveria necessidade de a citada lei mencionar a exigência de ser o réu "primário e de bons antecedentes". Ou seja, a meu juízo, qualquer processo em andamento tem o condão de configurar, para a negativa do aproveitamento da causa de diminuição em questão, óbice em virtude de maus antecedentes. Por essas razões, afasto a referida causa de diminuição, restando a pena privativa de liberdade imposta ao acusado redimensionada nesta instância para seis anos e três meses de reclusão [...] Em relação à pena-base, não há ilegalidade, pois houve concreta fundamentação, por parte da instância ordinária. Vê-se que 77 kg de maconha diz respeito a uma quantidade excessiva, de

modo que a exasperação foi feita dentro dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A redução da pena, na segunda fase, pela atenuante de confissão espontânea, foi feita em um critério que vem sendo aplicado pela jurisprudência, inexistindo assim necessidade de intervenção desta Corte Superior. Da mesma forma, o reconhecimento da causa de aumento, prevista no inciso V do art. 40 da Lei de Drogas se deu na fração mínima, sendo desnecessária qualquer alteração nesse sentido. No entanto, razão assiste à defesa, em relação ao pleito de ser reconhecido o privilégio, art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, uma vez que a fundamentação utilizada pela Corte Local para o seu afastamento foi de processos em andamento, o que vai contra o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No caso, o paciente é primário e sem antecedentes, uma vez que inexistente processo transitado em julgado. Sabe-se que [...] a teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas [...] (AgRg no HC n. 578.806/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/6/20). Assim, deverá ser restabelecida a sentença quanto ao reconhecimento da causa de diminuição da pena, na fração de 1/6, e a reprimenda definitiva para o paciente passa a ser de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa. Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para redimensionar a pena do paciente para 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa (STJ - HC: 591477 RS 2020/0151534-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 03/08/2020). Grifo nosso. Ainda, Apelação criminal – Tráfico de substâncias entorpecentes – Sentença condenatória – Pretendidas a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, a aplicação do redutor previsto no mesmo diploma legal, no grau máximo, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos – Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e dolo suficientemente demonstrados – Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos – Razoável quantidade de maconha e cocaína apreendida, dividida em porções individuais, prontas para entrega ao consumo – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas e regime escorreitamente fixados – Apelante que, embora não possuidor de maus antecedentes, demonstra dedicação a atividades criminosas – Processos em andamento que, malgrado não possam ser utilizados para o reconhecimento dessa circunstância, vedam a aplicação do redutor do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas – Mantido o afastamento do privilégio, ante o não preenchimento dos requisitos legais – Gravidade concreta da conduta do réu que revela elevada danosidade social, a reclamar, portanto, a manutenção do regime eleito, servindo, de resto, ao lado do novo quantum punitivo, como obstáculo à substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00076606120158260635 SP 0007660-61.2015.8.26.0635, Relator: Moreira da Silva, Data de Julgamento: 31/01/2019, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/02/2019) Grifo nosso.

Diante de tais considerações, é de se afastar a incidência, em concreto, da causa de diminuição em tela, mantendo a pena no patamar fixado. Mesmo para os crimes hediondos ou a eles equiparados cometidos na vigência da Lei nº 11.464/2007, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da pena imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto, para que, então, seja escolhido o regime carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção e repressão do delito perpetrado (HC n. 273.348/SP, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/2/2014). In casu, fixo o regime inicial de cumprimento de pena em fechado. A fixação do regime mais gravoso é imposta no caso em tela, considerando suas peculiaridades. Trata-se de delito com imputação de aumento de pena e não pode passar despercebido o fato de que o réu se dedica a atividades criminosas, conforme acima mencionado.

Assim, o regime mais gravoso é de rigor no caso, sendo regime mais brando incompatível com a gravidade concreta dos fatos.

Nesse sentido, têm-se julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Assim, fica o réu definitivamente condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no patamar estabelecido.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos, o que impede a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva, para CONDENAR o réu PEDRO AFONSO OLIVEIRA GOMES como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no patamar estabelecido.

O acusado respondeu a este processo preso e nada há nos autos que altere o referido cenário. Conforme a determinação do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade em relação aos fatos aqui apurados, uma vez que a permanência dele no cárcere é necessária para a manutenção da ordem pública. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o fumus comissi delicti decorre da própria procedência da pretensão punitiva veiculada na denúncia, havendo prova da materialidade e indícios de autoria do crime atribuído. O periculum libertatis, por sua vez, é evidenciado pela gravidade em concreto do crime praticado pelo réu, do risco concreto de ele voltar a delinquir, bem como da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não existem garantias de que em liberdade não se afastarão do distrito da culpa. Recomende-se ao cárcere em que se encontra e expeça-se guia de execução provisória.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal e o artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do valor apreendido em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Custas na forma da lei.

Ante o convênio celebrado entre a PGE/OAB, arbitro os honorários advocatícios do patrono nomeado em 100% do valor da tabela, se não houver recurso, e em 70% do valor da tabela, se houver recurso, expedindo-se a certidão.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

Sao Jose do Rio Pardo, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA